

大法官講堂：

中華民國憲法及政府（二）

第六講

總統

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

總 統

-- 虛位或實權國家元首的制度抉擇

湯德宗

憲法有聲書

目 次

壹、總統的定位

一、憲法變遷

1. 本文（虛位總統）→ 臨時條款（戰時總統）→ 1997
四次憲改（實質上指揮行政的實權總統）
2. 變遷背景
 - 歷史：帝制傳統影響 & 聖君賢相憧憬
 - 國內：鞏固領導權威 & 順應民主潮流
 - 國際：維護主權獨立 & 反制一國兩制

二、代表國家（§35）

1. 國家元首(head of state)

Q 副總統可否兼任行政院長？

釋字 419（85/12/31）：「副總統得否兼任行政院院長憲法並無明文規定，副總統與行政院院長二者職務性質亦非顯不相容，惟此項兼任如遇總統缺位或不能視事時，將影響憲法所規定繼任或代行職權之設計，與憲法設置副總統及行政院院長職位分由不同之人擔任之本旨未盡相符。」

📖 湯德宗，〈大法官有關行政、立法兩權關係主要解釋析論〉，輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立

新論・卷一》，頁 180（2014 年，增訂四版）。

Q 釋字 419 於今仍有適用？

書 湯德宗，〈新世紀憲改工程 -- 「弱勢總統制」改進方案〉，輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立新論・卷一》，頁 53 以下（2014 年，增訂四版）。

Q 現制下，總統（國家元首）得自兼行政院長（政府元首 head of government），直接指揮行政？

三、統率三軍（§36）

1. 三軍統帥與國家元首

Q 何以規定「總統統率軍隊」？

Ω 國家元首（§35）& 軍隊國家化（§§138, 139）

2. 「統率」與「統帥」有別？

Q 「統率」者「統而率」，「統帥」者「統而不率」？

2.1 軍政、軍令二元化

總統掌軍令，行政院長掌軍政（雙元行政結構？）；

參謀總長為總統（軍令系統）之幕僚長，並為部長（軍政系統）之幕僚長。

- 國防部組織法（67/07/17 修正公布）§§1, 5, 13

- 國防部參謀本部組織法（67/07/17 制定公布）§§3, 9

Q 何以有此設計？

Q 可行？

Q 參謀總長須至立法院備詢？

Cf. 釋字 461

書 湯德宗，〈大法官有關行政、立法兩權關係主要解釋析論〉，輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立新論・卷一》，頁 178（2014 年，增訂四版）。

2.2 軍政、軍令一元化

國防部主管全國國防事務（軍政、軍令、軍備）；參謀總長為部長之軍令幕僚長。

- 國防法（89/01/15 制定, 101/06/06） §§7, 8, 11, 13, 14
- 國防部組織法（89/01/15 修正全文, 91/01/15） §6
- 國防部參謀本部組織條例（90/11/12 修正全文） §2
→ 嗣國防部參謀本部組織法（101/12/12 制定公布）
刪除

四、副署（§37）

1. 意義

旨在彰顯決策責任（亦決策權力），為內閣制之特徵（蓋國家元首既屬虛位，行政元首／總理掌握實權，故爾）

2. 變遷

2.1 縮小副署範圍

- 第三次增修 §2-II & §2-III（附條件免職／建設性倒閣）

2.2 由量變而質變

- 第四次增修 §2-II & §3-I（平行伙伴→ 上下隸屬）

貳、總統職權

一、公布法令（§37；增修 §2-II）

1. 「依法」

Q 「依法」含「依憲法」？

Q 經立法院覆議維持原決議之法案，猶需送總統公布？

Ω 93/09/14 立法院以 114 票否決行政院所提「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」覆議案，嗣陳水扁

總統於 93/09/24 以華總一義字第 09500058961 號令公布，並加註意見：「本條例部分條文容有違憲之重大爭議，宜尋求釋憲或修法解決，俾符憲政法理」。

二、締約、宣戰、媾和（§38）

1. 「依本憲法規定」

§58-II & §63

2. 「條約」

- 條約及協定處理準則（81/02/19）§§3, 8, 9
- 釋字 329（82/12/24）

→ 條約及協定處理準則（83/03/11）§§3, 9, 10

📖 湯德宗，〈大法官有關行政、立法兩權關係主要解釋析論〉，輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立新論·卷一》，頁 185（2014 年，增訂四版）。

三、宣告戒嚴（§39）

1. 何謂「戒嚴」（état de siege, state of siege）

- 本質：軍管備戰（戒嚴法 §7 = 軍管）
- 事由：戰爭或叛亂（戒嚴法 §1-I）

2. 程序

- 「依法」→ 戒嚴法（38/01/14）
- 一般：行政院會議議決＋立法院通過（戒嚴法 §1-I）
- 緊急：行政院呈請＋總統宣告＋1 個月內立院追認（戒嚴法 §1-II）；
- 臨時：部隊長＋迅速逐級呈請立院追認（戒嚴法 §3）

📌 總統宣告戒嚴之「命令」，須經行政院長副署？

3. 內容

- 重大刑案得劃交軍事審判（戒嚴法 §8）

Ex：李師科土地銀行搶案 v. 高雄縣彌陀郵局搶案

- 得全面限制人權（戒嚴法 §11）

4. 回復

- 移請解嚴：戒嚴法 §12（立法院移請總統解嚴）
- 自行解嚴：台灣地區戒嚴（38/05/20～76/07/15）
金門縣、連江縣戒嚴（38/05/20～81/11/07）

5. 解嚴效力

Q 一律回復原狀（戒嚴法 §12）？

5.1 原經軍事審判案件之處理

動員戡亂時期國家安全法（76/07/01）§9

5.2 戒嚴時期人民受損權利回復條例（84/01/28 →
89/02/02 修正）

Q 適用範圍得以犯「內亂、外患」罪者為限？

Ω 釋字 477（屬立法裁量之範圍）

Q 得僅限「於受無罪判決確定前曾受羈押或刑之執行者」，始得請求賠償？

Ω 釋字 477（立法之重大疏失 = 基本權保護不足？）

5.3 戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例
（87/06/17 制定公布, 95/12/18）

→財團法人戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償
基金會

四、赦免（§40）

1. 「依法」赦免

- 赦免法（80/09/24）

2. 種類及效力

- §2（大赦）

- §3 (特赦)

Q 「特赦」有溯及既往之效力？

Ω 釋字 283 (並參 §5 之 1)

- §4 (減刑)

- §5 (復權)

3. 發動權

§6：「總統得命令行政院轉令主管部研議」

五、任免官員 (§41)

1. 「依法」

1.1 文官

公務人員任用法 (102/01/23) §25 (簡任、薦任公務人員呈請總統任命)

1.2 武官

陸海空軍軍官士官任官條例 (102/05/22) §16：(軍官呈總統任之)

六、授予榮典 (§42)

1. 「依法」

- 褒揚條例 (75/11/28) §§1, 3 (褒揚方式)
- 勳章條例 (70/12/07) §2 (勳章五種類)
- 陸海空軍勳賞條例 (41/05/24) §2 (勳賞七種類)

七、緊急命令 (§43)

1. 沿革

- 臨時條款 §1 (緊急處分)
- 1991 一次增修 §7 (緊急命令):
放寬事由，縮短追認期間，不另立法
- 1992 二次增修 §7
- 1994 三次增修 §2-IV
- 1997 四次增修 §2-III
- ~

內容相同

2. 實體要件

- 天然災害、瘟疫、國家財經重大變故 (§43)
- 緊急危難、財經重大變故 (臨時條款 §1)
- 緊急危難、財經重大變故 (增修 §2-III)

3. 程序要件

3.1 限於立法院休會期間 (§43)

3.2 經行政院會議決議

3.3 送立法院追認：1 個月 (§43) → 10 日 (增修 §2-III)

Q 立法院應如何「追認」？須「全案」表決？

Q 應循如何程序？

Ω 立法院職權行使法 (99/06/15) §15

3.4 依「緊急命令法」？

4. 建制目的 (本質限制)

既係為應變 (參前揭「實體要件」)，自應限於應變所「必要之處置」(「必要性」或「比例原則」)

5. 「緊急命令」之法位階

5.1 總統於緊急情況下之「特殊」立法權

「緊急命令」乃「法律保留」原則之例外

「緊急命令」使國家「立法權」由一元暫時變為二元

5.2 「緊急命令」相當於「法律」，並得按「後法優於前法」原則，排除現行之適用，或補充現行法所無之規定

5.3 釋字 543

「緊急命令係總統為應付緊急危難或重大變故，直接依憲法授權所發布，具有暫時替代或變更法律效力之命令」

6. 國會監督

- 理論基礎：二元立法權乃屬例外

- 監督方式

Q 「追認」已足監督？

Q 得隨時決議「失效」或「限期失效」？

Q 國會無法集會時，應如何監督？

Q 立法院在九二一地震緊急命令（88/09/25）有效期間內（迄 89/03/24）通過「九二一震災重建暫行條例」（89/01/15），應如何理解？

7. 司法監督

7.1 違憲審查（合憲性審查）

- 具備實質要件？此屬「政治問題」，不受司法審查？
- 符合程序要件？

7.2 行政訴訟（合法性審查）

- 衍生之「行政處分」，是否逾越「緊急命令」？
- 「緊急命令執行要點」逾越「緊急命令」？

8. 「緊急命令」得衍生「執行要點」？
1999/09/21 大地震，總統於 09/25 發佈「九二一大地震緊急命令」，立法院 09/28 追認通過。行政院於 10/21 訂頒「中華民國八十八年九月二十五日緊急命令執行要點」，函送立法院「督知」，立法院於 10/29 決議「准予備查，不必交付審查」。
 - 「執行要點」須在「緊急命令」中獲得確切授權？
 - 誰有權訂定「執行要點」？
9. 「執行要點」之定位
 - 相當於「法規命令」？
 - 須受國會監督

Q 「督知」=「備查」？
10. 「緊急命令」法制化
 - 需制定「緊急命令法」？

Q 「緊急狀況」能夠類型化？
E.g., 「災害防救法」(89/07/19 制定公布, 101/11/28)
- 緊急命令之「內容」應「限時、限地」？

八、院際調解 (§44)

1. 院際爭議調解權
 - 「適用憲法產生疑義」非屬「院與院間之爭執」？
釋字 3
釋字 76
 - 「適用憲法產生爭議」屬「院與院間之爭執」？
E.g., 釋字 520 (核四停建權歸屬?)
2. 「除本憲法有規定者外」？

九、大政方針決定權

1. 臨時條款 §4

1.1 打破「權力分立」(國家安全會議組織綱要 (56/02/01 制定公布, 63/05/03) § 6-II)

1.2 決議應付執行(國家安全會議組織綱要 §9)

2. 1991 一次、1992 二次增修 §9-I

國家安全會議組織法(82/12/30) §2 (「國家安全會議，為總統決定國家安全有關之大政方針之諮詢機關」)

Q 終止動員戡亂，理應回歸憲政？

3. 1994 三次增修 §2-V

4. 1997 四次增修 §2-IV

國家安全會議組織法(92/06/25) §2-II (「國家安全係指國防、外交、兩岸關係及國家重大變故之相關事項」)

Q 得以「法律」劃分總統與行政院之行政權？

十、被動解散立法院權

1997 四次增修～ § 2-V

Q 「被動」(解散立法院)之意義？

Q 總統得不從行政院長之請求，逕自解散立法院？

十一、提名權

1. ~~行政院院長~~ (§55-I 提名→ 增修 §3-I 任命)

2. 司法院院長、副院長、大法官 (§79, 增修 §5-I)

3. 考試院院長、副院長、考試委員 (§84, 增修 §6-II)

4. 監察院院長、副院長、監察委員 (增修 §7-II)

5. 審計長 (§104)

參、總統之選舉、罷免

一、被選資格與選舉方式

1. 資格

1.1 年齡限制 (§45)

Q 何以設年齡限制？

Q 屬「年齡歧視」(age discrimination)，違憲？

1.2 身分限制 (總統選罷法 (98/05/27) §27)

Q 法律得增加憲法所無之「限制」？

1.3 設籍限制

總統副總統選舉罷免法 (98/05/27) §20-I (連續居住
台灣地區 6 個月以上，且設籍滿 15 年)

1.4 國籍取得限制

總統選罷法 §20-II (回復國籍、歸化國籍、大陸地區人
民不得登記)

1.5 消極資格 (總統選罷法 §26)

2. 選舉方式

2.1 憲 §§27, 46 → (舊)總統副總統選舉罷免法 (43/03/13,
88/12/15 廢止) §4-I (以獲得國代總額過半數者為當選)

2.2 增修 §2-I：聯名登記、同組圈選、以相對多數為當選

2.3 政黨推薦

每政黨限推薦一組候選人 (總統選罷法 §22-I)；
並以次大選獲得 5% 選票之政黨為限 (總統選罷法
§22-II)

Q 政黨推薦門檻，違憲？

2.4 自行連署

繳交保證金一百萬元 (總統選罷法 §23-I)；

45 天內連署人數未達上次大選選舉人總數 0.75%者，
沒收保證金（總統選罷法 §23-IV）

Q 連署保證金，違憲？

Cf. 釋字 468

肆、總統之就任與去職

一、任期（增修 §2-VI）變遷

1. 六年，連選得連任一次（憲 §47）→
2. 臨時條款 §3（連選得連任，不受憲 §47 之限制）→
3. 1991 一次增修（回復憲法 §47 之效力）
4. 1992 二次增修 §12-III→（1994 三次增修～ §2-VI）改成四年

Q 何以縮短任期？

Ω 民意求新（人民直選）、大權在握（不宜久任）、典範影響（美總統制）

二、宣誓（§48）

1. 何以將誓詞明定於憲法？
總統副總統宣誓條例（§4 大法官會議主席監誓）
2. 宣誓之效力？
準用釋字 254？
📖 湯德宗，〈大法官有關「權力分立原則」解釋案之研析〉，輯於氏著《違憲審查與動態平衡：權力分立新論・卷二》，頁 381（2014 年，增訂四版）。

三、繼任與代行

1. 繼任（§49；釋字 419 [1]）
總統缺位，副總統繼任；均缺位時，行政院長召集國大

臨時會補選；

→ 1992 二次增修 §12-V & §12-VI

副總統缺位，總統召集國大臨時會補選；

均缺位時，由立法院長召集國大臨時會補選

→ 1994 三次增修 §2-VII

副總統缺位，總統於三個月內召集國大臨時會補選

2. 代行 (§§49, 50, 51；釋字 419 [1])

→ 增修 §2-VIII

(均缺位時，行政院長代行職權，並舉行直選)

Q 行政院長代行職權是否亦不得逾三個月期限？

四、罷免與彈劾

1. 罷免 (§27-I-(2)→ 增修 §2-IX)

- 本文 (§27-I-(2))

國大罷免→

(舊)總統副總統選舉罷免法(43/03/13, 88/12/15 廢止)

§9-I (以代表總額過半數之贊成票通過之)

- 1992 二次增修 (§12-IV-(1))

國大罷免 (1/4 國大提議 & 2/3 國大同意)

- 1994 三次、1997 四次、1999 五次增修 國大提出 (§2-IX 前：1/4 提議 & 2/3 同意) +

人民複決 (§2-IX 後：選舉人總數過半投票 & 有效票過半同意。)

- 2000 六次增修

立委提出 (§2-IX 前：1/4 提議 & 2/3 同意) +

人民複決 (§2-IX 後：選舉人總數過半投票 & 有效票過半同意)

2. 彈劾

- 本文 (§100)

監院向國大提出→

(舊) 總統副總統選舉罷免法 (43/03/13, 88/12/15 廢止) §10-II (以出席國代三分之二之同意行之)

- 1992 二次增修

監院 (§15-V : 1/2 提議 & 2/3 決議) 向國大提出 ;
國大議決 (§12-IV-(2) : 2/3 同意後解職)

- 1994 三次、1997 四次、1999 五次增修

監院 (§6-V : 1/2 提議 & 2/3 決議) 向國大提出 ;
國大議決 (§2-X : 2/3 同意後解職)

→ 國民大會議決總統副總統彈劾案辦法 (87/07/30)

- 2000 六次增修

立法院 (§4-VII : 1/2 提議 & 2/3 決議) 向國大提出 ;
國大議決 (§2-X : 2/3 同意後解職)

- 2005 七次增修

立法院提案 (§4-VII : 1/2 提議 & 2/3 決議) + 憲法法庭審理 (相關程序?)

→ 司法院大法官審理案件法修正草案(102/01/08)

§§ 71~77

伍、總統之特權

一、刑事豁免特權(immunity privilege) (§52)

1. 範圍：內亂、外患罪以外之犯罪

2. 期間：任期內 (罷免、解職後仍受刑事訴究)

Q 「現任」總統參選（次屆總統）時，亦有適用？

Ω 釋字 388

3. 釋字 627

- 為何予總統「刑事豁免特權」？
- 性質
絕對或相對豁免？
永久或暫時豁免？
- 得放棄？

Q 何謂「原則上不得拋棄」？

二、行政特權(executive privilege)

1. 由來

- 釋字 585（行政特權）
- 釋字 627（國家機密特權）

2. 內容

- 國家機密特權為「行政特權」之一部分
- 總統就其職權範圍內「有關國家安全、國防及外交資訊之公開，認為有妨礙國家安全與國家利益之虞者，應負保守秘密之義務，亦有決定不予公開之權力」，是為總統之國家機密特權。

Q 總統「國家機密特權」與「憲法結構」之關係？

Q 我國現制下「總統職權」？

Q 總統釋明：拒為相關證言或提交相關證物，乃因有妨害國家利益之虞，倘承辦檢察官或審判庭法官依保密程序審酌後，認為「未有造成國家安全危險之合理顧慮者」，應如何處理？

《對話憲法・憲法對話》2015

三、退休禮遇

卸任總統副總統禮遇條例（99/09/01）

- 應邀參加國家大典（§2-I）
- 禮遇金（§2-II）
- 事務費（§2-III）
- 保健醫療（§2-IV）
- 安全護衛（§2-V）

【學思策問】

Q 憲法上之總統職權，何以屢屢變遷？

Q 直選總統得兼任行政院長，以提升行政效率？

【進階閱讀】 湯德宗，〈副總統兼任行政院長釋憲案鑑定意見書〉，輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立新論・卷一》，頁591～598（2014年，增訂四版）。

R. Kent Weaver & Bert A. Rockman, *Institutional Reform and Constitutional Design*, in *DO INSTITUTIONS MATTER?* (R. Kent Weaver & Bert A. Rockman ed.) 462-481 (1993).